

1500071-58.2022.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMILIO RODRIGUES DE SOUSA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

EMILIO RODRIGUES DE SOUSA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500071-58.2022.8.26.0550 -
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500071-58.2022.8.26.0550 - 2022/000098

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMILIO RODRIGUES DE SOUSA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

EMILIO RODRIGUES DE SOUSA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque, no dia 04 de fevereiro de 2.022, por volta das 06:45 horas, na Rodovia SP 310, km 197, no município de Corumbataí, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, transportava 2.520 (dois mil quinhentos e vinte) microtubos do tipo eppendorf contendo a substância entorpecente denominada cocaína, totalizando peso líquido aproximado de 333,7 gramas, 01 (um) invólucro contendo a mesma substância entorpecente denominada cocaína, na forma de crack, totalizando peso líquido de 99,0 gramas, e 14 (quatorze) invólucros plásticos contendo a substância entorpecente denominada tetrahidrocannabinol, totalizando peso líquido aproximado de 35,1 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação de fls. 17/19 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 79/81, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 18 de abril de 2022.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, inviabilizando-se, entretanto, dada as circunstâncias reveladoras de dedicação à atividade ilícita, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, devendo ser a pena cumprida em regime prisional inicial fechado, por conta da hediondez do delito, impondo-se ainda o perdimento do veículo, porque preparado para o transporte do entorpecente.

Já a ilustre Defensora, à vista da confissão externada pelo acusado, sustentou tratar-se de agente primário, que não integra organização criminosa, tampouco estava dedicado à atividade ilícita, devendo incidir a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. as disposições da Lei nº 8.072/90, assim porque transportava, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 79/81, com resultado positivo para cocaína, identificando-se também em parte da substância apreendida o elemento tetrahidrocannabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha. Incontroversa também a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

De fato, ouvido em Juízo, o acusado voltou a admitir que na ocasião dos fatos estava realmente conduzindo seu veículo pela Rodovia Washington Luís, quando abordado por Policiais Militares Rodoviários, confirmando que transportava a expressiva quantidade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha) em um compartimento especialmente preparado para tanto, tendo como destino a cidade de Itirapina. Conquanto somente na fase inquisitória - em juízo negou tivesse afirmado --, esclareceu que já era a quinta vez que realizava o transporte de entorpecentes.

A não se dizer isolada, a confissão externada pelo acusado foi amparada pela prova pericial e oral produzidas.

O policial militar rodoviário Anildo Pedro afirmou que na ocasião estava realizando uma fiscalização na base localizada na Rodovia Washington Luís, município de Corumbataí, quando abordado o acusado na condução de um veículo Fiat, de cor prata. Após a solicitação de exibição dos documentos necessários, logo sentiu forte odor de maconha, negando o acusado tivesse feito uso deste entorpecente. No entanto, diante desta circunstância, em busca veicular, notou que havia um compartimento não original, sob o porta-luvas. Examinado com maior cuidado, verificou que havia algo no interior deste compartimento, então tendo o

acusado observado que estava transportando entorpecente, acionando um dispositivo localizado atrás do rádio, de modo que possibilitou a abertura daquele compartimento, em cujo interior foram apreendidas as duas mil, quinhentos e vinte porções de cocaína, várias porções de maconha e uma pedra bruta de crack. Acrescentou a testemunha que o acusado, naquela oportunidade, afirmou que já era a quinta vez que realizava o transporte de entorpecente para a cidade de Itirapina, sendo da cidade de Sumaré.

Como se tem rotineiramente consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais militares envolvidos nas diligências. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Assim, para além da confissão externada pelo acusado, esclareceu o Policial Militar Rodoviário as circunstâncias que determinaram a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, acondicionado, ademais, em compartimento especialmente preparado para o transporte, em veículo pertencente ao acusado, compondo substrato probatório que permite seguro juízo de convicção sobre a realidade da imputação inicial.

De outra parte, cumpre seja acolhido o reclamo de imposição da pena de perdimento sobre o veículo pertencente ao acusado. Não se ignora que "para não chegar a um resultado abusivo, deverá a autoridade determinar a perda apenas dos instrumentos do crime, e não os que ocasionalmente estejam ligados à conduta criminosa. A excessiva amplitude dos arts. 74, II, "a", do CP e da Lei Antitóxicos exige interpretação restritiva para não se chegar ao absurdo de decretar a perda de um automóvel porque nele foi encontrado tóxico, sem a existência, entretanto, de nexo etiológico entre o delito e o objeto utilizado para a sua prática".

Em outro dizer: "se não demonstrado o vínculo de uso do veículo de propriedade do acusado no comércio da droga apreendida não há como retê-lo com o fim de confisco".

E, por fim: "os veículos encontrados na posse de agentes condenados por tráfico de entorpecente somente poderão ser confiscados quando, efetivamente, estiverem sendo usados, devidamente preparados, para o exercício do comércio criminoso" (apud. Marcão, Renato - Tóxicos, 4ª Ed. p.550/552).

No caso, como reconhecido pelo próprio acusado (fls. 4) e evidenciado pela prova oral produzida, o veículo pertencente ao acusado contava com compartimento especialmente preparado para o transporte do entorpecente, havendo indicação de que isto já ocorria por variadas vezes, de tal modo que deve ser alcançado pela pena de perdimento, não se estendendo aos valores apreendidos porque, neste caso, não há demonstração de que decorresse da atividade ilícita.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de

Tóxicos, diante da expressiva quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, deve a pena-base ser fixada pouco acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, deve a pena-base retornar ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

E não se mostra possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. É que não apenas lhe foi confiado o transporte de quantidade expressiva de entorpecentes, a revelar já por isto vínculo com a atividade criminosa, como também e especialmente porque o fazia em seu próprio veículo, que foi preparado para tanto, com a criação de um compartimento onde poderia ser armazenado e escondido o entorpecente, dotado de mecanismo de abertura escamoteado, o que evidentemente não indica situação episódica, mas envolvimento mais aprofundado e dedicado com a referida atividade criminosa, isto se inferindo ainda porque destinado o entorpecente à cidade de Itirapina, não pela demanda, já que se trata de município de pequena densidade demográfica, mas pela existência de unidades prisionais, em torno das quais gravitam expedientes de organizações criminosas.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado EMÍLIO RODRIGUES DE SOUSA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, diante da situação econômica do acusado, corrigido desde a época do fato, operando-se ainda o perdimento do veículo apreendido em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Sobre o regime inicial de cumprimento da pena, e considerando a natureza hedionda do delito, por equiparação, atendendo comando constitucional (art. 5º, XLIII, CF), dispõe o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, que deve a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, introduzindo a progressividade, a fim de sanar vício da redação inicial que determinava o integral cumprimento da sanção em regime prisional fechado, o que atentaria contra o princípio da individualização da pena.

Não se ignora que, ainda esta alteração, com disposição de início em regime fechado, foi também considerada inconstitucional, em caráter incidenter tantum, no HC nº 111.464/ES, sendo Relator o Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos, entendendo-se padecer do mesmo vício de violação ao princípio da individualização da pena, devendo ser fixado o regime prisional, mesmo em se tratando de delitos hediondos e equiparados, na forma do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Nada obstante a autoridade da mencionada decisão, promanada do Pretório Excelso, em controle difuso, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade, e considerando a controvérsia que marca a questão, até mesmo no âmbito da Suprema Corte, já que a decisão foi tomada por maioria de votos, possível dizer, com a mais elevada vênia, que em função do comando previsto no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, cuidou o legislador infraconstitucional em estabelecer tratamento mais rigoroso para o cumprimento da pena de alguns delitos (hediondos e equiparados) dada a maior gravidade da violação aos bens juridicamente protegidos, por isto se estabelecendo no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a alteração dada pela Lei nº 11.464/07, que a pena seria cumprida em regime prisional inicial fechado.

Não se entende, renovada a vênia, tenha a disposição legal violado o princípio da individualização da pena, porquanto, não obstante a limitação ao regime inicial mais gravoso, como ocorre em situações outras, dada a valoração legitimamente exercida pela atividade legislativa, tendo como fonte o anseio de se reprovar de forma distinta ações delitivas que causam maior perturbação ao meio social, não se

tem por interdita a progressividade no cumprimento da pena, tampouco os benefícios do livramento condicional e a remissão, o que assegura a individualização da sanção, sem descuidar de suas funções retributivas e preventivas, além de ressocializadoras.

Como se tem objetado, se o regime inicial obrigatoriamente fechado é inconstitucional, por conta de critérios qualitativos (crimes hediondos e equiparados), também o seria pelo critério quantitativo da regra prevista no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, que prevê obrigatoriamente regime prisional inicial fechado no caso de pena superior a 8 (oito) anos.

Além disto, submetendo a individualização da pena em casos de delito hediondo ou equiparado tão somente às regras gerais previstas no artigo 33, §2º, do Código Penal, estar-se-ia retirando eficácia do comando inserto na Constituição Federal que determinou a adoção de tratamento diferenciado mais rigoroso nestas hipóteses (cf. art. 5º, LXIII, CF).

Deste modo, a pena cominada ao acusado deverá ser inicialmente cumprida em regime prisional fechado, não se lhe facultando a interposição de recurso em liberdade, já que persistem os fundamentos que determinaram a prisão cautelar, potencializados pela sentença condenatória, sem prejuízo de eventual progressão em sede de execução provisória. Sobre isto: "O direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva. A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9, do STJ)" (HC nº 86907/RS, Rel. Min. Felix Fisher, DJU. 14.04.2008, p.1).

E, especificamente aqui, "a apelação em liberdade prevista no art.59 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a cumulação dos pressupostos da primariedade e da inexistência de antecedentes com o fato de ter o réu respondido em liberdade a ação penal, tanto pela inoccorrência de prisão oriunda de flagrante delito quanto pela inexistência de decreto de prisão preventiva" (HC - Agr. 94.521/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º.08.2008).

E, por fim: "o agente que responde a todo o processo por tráfico ilícito de entorpecente preso não tem o direito de aguardar o recurso interposto pelo Órgão Ministerial em liberdade, mesmo tendo a sentença contra si prolatada substituído a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária e serviços à comunidade, eis que a efetividade imediata da pena substitutiva, configuraria em execução provisória" (TJSP, HC 387.079-3/4, 5ª Câmara, Rel. Des. Gomes de Amorim, v.u., RT807/605, apud RENATO Marcão, Tóxicos, 4ª ed.p.527).

Por fim, diante do quantum da pena aplicada, não incide as disposições previstas no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e, oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, promovendo-se a restituição dos valores apreendidos com o acusado e comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA